



בפני המפקח על רישום המקרקעין בבאר שבע

תיק מס' 74/09

בעניין:

ר.ס. סיטי ניהול בע"מ ח.פ. 51-311660-8

ע"י ב"כ עוה"ד ינון פריד

ה ת ו ב ע ת

- נ ג ד -

זמיר שירותי כח אדם בע"מ ח.פ. 51-094363-2

ע"י ב"כ עוה"ד דוד כהן ו/או עמית כהן

ה ת ו ב ע ת

פ ס ק - ד י ן

עניינה של ה תובענה בדרישתה של התובעת, כי הנתבעת ת שלם את חלקה בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף של הבית ברחוב הנרייטה סולד 8 בבאר שבע, המסתכם, כך לטענתה, עד ליום 31.12.03, בסך של 86,787 ₪.

א. תמצית העובדות שאין עליהן מחלוקת:

1. המדובר בבית ברחוב הנרייטה סולד 8 בבאר שבע, הידוע בכינוי "רסקו סיטי" והרשום כיום בפנקס הבתים המשותפים בגוש 38016 חלקה 42 בבאר שבע (להלן: "**הבניין**"). כבר עתה יצוין, כי במועד הרלוונטי טרם נרשם הבניין כבית משותף.
2. מי שיזמה את בניית הבניין הינה חברת ריאלקו (חברה להשקעות במקרקעין) בע"מ (להלן: "**ריאלקו**"), אשר שיווקה אותו לדיירים שונים, וקיבלה על עצמה את ניהול וביצוע השירותים בבניין.
3. הנתבעת הינה בעלת זכויות בדירה בבניין.

4. ביום 10.8.99 נכרת הסכם בין הנתבעת לבין ריאלקו, שעניינו ניהול, אחזקת וניקיון הבניין (להלן: "**הסכם הניהול**"). בסעיף 2 להסכם הנ"ל נקבע כי: "החברה מקבלת על עצמה את ניהול וביצוע השירותים בבנין והדייר מסכים לכך ומוסר לחברה את ניהול וביצוע השירותים בכל הנוגע לזכויותיו בנכס". בסעיף 9.1 להסכם נקבע עוד כי: "הדייר מתחייב לשאת ביחד עם יתר הדיירים בכל ההוצאות הסבירות הכרוכות בניהול וביצוע השירותים על ידי החברה", ובסעיף 9.5 להסכם נקבע כי "בתמורה לטיפול החברה בניהול וביצוע השירותים בהתאם להסכם זה, ישלם הדייר לחברה דמי ניהול בש יעור של 15% מכל ההוצאות הסבירות הקשורות בניהול וביצוע השירותים (להלן: "**דמי הניהול**")".
5. בסעיף 5 להסכם הנ"ל נקבע גם, כי ריאלקו תהא זכאית להמחות ולהסב את זכויותיה לחברת ניהול אחרת, ואכן, ביום 25.6.01 נחתם בין ריאלקו לבין התובעת, ר.ס. סיטי בע"מ (להלן: "**ר.ס. סיטי**") הסכם, במסגרתו הוסבו כל זכויותיה וחובותיה של ריאלקו לתובעת, החל מיום 1.8.01.
6. ביום 8.1.04, הגישה התובעת כתב תביעה בסדר דין מקוצר במסגרתו טענה, כי הנתבעת לא העבירה את התשלומים הדרושים במלואם, וכי בגין התקופה שמיום 1.8.01 ועד ליום 31.12.03, הצטבר לנתבעת חוב של 86,787 ₪.
7. תביעה זו עברה גלגולים רבים עד ש בסופו של יום הועברה לפתחי, מבית משפט השלום בבאר שבע, בהתאם להוראות סעיף 79 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 (להלן: "**חוק בתי המשפט**").
8. קודם להעברת התיק אלי, מינה בית משפט השלום בבאר שבע את המהנדס מר אורמן דן, כמומחה מטעם בית המשפט, ובעקבות העברת התובענה למפקח על רישום המקרקעין, נשמעה עדותו של מר אורמן בפניי ביום 30.11.10.
9. בסופו של דיון ההוכחות קבעתי כי הצדדים יסכמו בכתב, וכן קבעתי כי: "הסיכומים יעסקו בכל הנושאים שבמחלוקת. אם יתברר, כי ישנן מחלוקות עובדתיות נוספות הדרושות להכרעה, יוזמנו הצדדים לדיון הוכחות נוסף. ככל שלא יהיה צורך בכך, יינתן פסק דין על פי החומר הקיים בתיק".
10. בעקבות זאת הגישו שני הצדדים סיכומיהם בכתב.

ב. טענות התובעת:

11. לטענת התובעת, התחייבות הנתבעת כלפיה הינה, בראש ובראשונה חוזית, וזאת, מכח הסכם הניהול עליו חתמה הנתבעת עם ריאלקו, ואשר התובעת נכנסה בנעליה. בנוסף, כך לשיטתה של התובעת, חבותה של הנתבעת נובעת גם מהוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"), הקובע כי על הנתבעת לשאת בהוצאות

אחזקתו וניהולו של הבית המשותף. בהקשר לכך נטען על ידי התובעת, כי מדובר בשני רובדי חיוב המשלימים זה את זה, ובמקום שבו רובד אחד של חיוב אינו "מכסה" את החבות, הרי שהרובד הנוסף מבססה. כך למשל, לטענת התובעת, ייתכן שמכח חוק המקרקעין לא ניתן לחייב את הנתבעת בריבית פיגורים, אך חבות זו נגזרת מכח ההסכם עליו חתומה הנתבעת.

12. התובעת מפנה לעמוד 8 שורה 20 לפרוטוקול הדיון מיום 30.11.10, במסגרתו אישר ב"כ הנתבעת את חתימת מרשתו על הסכם הניהול. על כן, כך לשיטת התובעת, אין ספק כי הנתבעת חייבת לקיימו, ולשלם את הדרוש במסגרתו. לטענת התובעת, אין ספק כי ההוצאות שנקבעו על ידה הינן סבירות בנסיבות העניין, שכן מדובר בהוצאות רגילות ומקובלות בבנייני משרדים הדומים לבניין דן.

13. לטענת התובעת שיטת החיוב הינה נכונה וצודקת בנסיבות העניין, ועולה בקנה אחד הן עם הוראות חוק המקרקעין והן עם הסכם הניהול. בהקשר לכך סומכת התובעת טענותיה על דברי המהנדס המומחה מר דן אורמן, הקובע, לטענתה, כי שטח הברוטו של הנתבעת לצורך השתתפות בהוצאות הינו 221 מ"ר [סעיף 5.4 לחוות הדעת], ומכך נגזר חלקה היחסי של הנתבעת בין 2.5154% ל- 2.6207% [סעיף 5.4.7 לחוות הדעת]. התובעת מפנה לכך שרוב ההוצאות נקבעו על ידי המומחה כהוצאות סבירות ורק חלק קטן מהן נפסל על ידו. התובעת הפנתה לדברי המומחה כי סך כל הסכומים (קרן וללא מע"מ) שקבע המומחה מגיע לסך של 50,001 ₪.

14. מוסיפה התובעת וטוענת, כי במהלך חקירתו אישר המומחה כי ניתן לתקן את חוות הדעת ולהוסיף הוצאה נוספת שהינה הוצאה סבירה. המדובר על הוצאה בסך של 8,226 ₪ בגין "אגרות" [ר' עמוד 3 שורות 33-34 לפרוטוקול מיום 30.10.11].

15. התובעת הפנתה לדברי המומחה שחזר והעיד בעדותו, כי שיטת המדידה שהונהגה הינה מקובלת וסבירה, ואף העיד כי הוא מכיר בניינים אחרים בהם יחס ה"ברוטו" "נטו" לעיתים גבוה מזה שהונהג בבניין, ולעיתים נמוך [ר' שורות 6-9 בעמוד 6 לפרוטוקול].

16. התובעת טוענת, כי חוות הדעת של המומחה נותרה נאמנה ואמינה, וכי יש לקבלה בכפוף לתיקון האמור, ולהוסיף עליה מע"מ על פי דין והפרשי הצמדה וריבית כקבוע בהסכם או לפי שיעור אחר שייפסק על ידי המפקח.

17. התובעת מוסיפה וטוענת כי אי עמידת הנתבעת בהסכם הינה חסרת תום לב ועומדת בסתירה לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק החוזים"). התובעת מוסיפה כי הימנעותה של הנתבעת מהתשלום הנדרש ממנה פוגעת בכלל בעלי הזכויות בבניין, ועלולה לגרום בסופו של דבר לכך שלא ניתן יהיה לנהל את הבניין כיאות או להטיל נטל נוסף על יתר בעלי הזכויות.

18. התובעת טוענת עוד, כי גם על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין חובה על הנתבעת לשלם את החוב הנתבע ממנה לאחזקת הרכוש המשותף. לא זו אף זו, לשיטת התובעת, אף אם

חולקת הנת בעת על הסכום הנתבע , עליה להגיש תביעה מתאימה , ואין היא רשאית להפסיק לשלם את חלקה רק מפאת המחלוקת על גובה הסכום.

19. התובעת טוענת, כי גם ללא הסכם הניהול היתה התובעת רשאית לגבות מהנתבעת דמי ניהול, מכח דיני עשיית עושר ולא במשפט. התובעת מפנה בעניין זה לפסק הדין בתא"מ 8494-05-09 **שירותי מרכז פנורמה בע"מ נגד בנארי ואח'** (פורסם בנבו).

20. מוסיפה התובעת, כי יש לראות בתובעת כ **"מתחזק"** בהתאם לסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, שכן כל אחד מבעלי הזכויות בבניין הסכים למינוי חברת הניהול במסגרת חתימתו על הסכם הניהול. בהקשר לכך מפנה התובעת לפסק הדין בעש"א 5336-06-09, **ניהול שנקר 4 בע"מ נ' אבי זלצמן**, (פורסם בנבו). לפיכך, כך לטענת התובעת, יש לראות את הסכם הניהול כמחייב את כל בעלי הזכויות בבניין.

21. התובעת מפנה לפסק הדין בתא"מ (י-ם) 6420/07 **מירב מגדל מבוא ירושלים אחזקות בע"מ נ' סימה צי ליק ואח'** (פורסם בנבו), הקובע לשיטתה כי ניתן לראות בהוראה בהסכם הניהול, שלפיה המתחזק רשאי להמחות זכויותיו לאחר , הוראה העומדת בדרישות חוק המקרקעין. עוד טוענת התובעת, כי פסק הדין קבע שנוצר הסכם מכללא, מעצם העובדה כי התובעת מעניקה שירותים מזה זמן רב , ובעלי הדירות בבניין נהנים משירותים אלו. כך גם מפנה התובעת לקביעות פסק הדין , הקובעות, לטענתה, כי אי תשלום על שירותים שהתקבלו משך שנים מהווה עשיית עושר ולא במשפט.

22. לטענת התובעת סעיף 9.2 להסכם הניהול מקנה לתובעת את הסמכות לקבוע את הקריטריונים לחלוקת ההשתתפות בהוצאות הניהול, וסעיף זה מחייב את הנתבעת הן לאור דיני החוזים, והן לאור דיני המקרקעין. לשיטת התובעת, חתימת הנתבעת על הסכם הניהול, משנה למעשה את הוראות התקנון המצוי שבחוק המקרקעין, וזאת לאור הסיפא לסעיף 58 לחוק המקרקעין, וכן לאור הוראות סעיף 12(ב) לתוספת הראשונה ש בחוק המקרקעין. התובעת אף מפנה לכך כי רק ביום 18.8.08 נרשם תקנון הבית המשותף.

23. כך או כך , מסכמת התובעת, הוראות הסכם הניהול הן המחייבות במקרה דנן , ולפיכך חברת הניהול היא האחראית לקבוע את הקריטריונים לתשלום , כל עוד מדובר בקריטריונים סבירים , ובתנאי שמדובר בהוצאות סבירות. על כן, טוענת התובעת, יש לחייב את הנתבעת במלוא הסכום שנקבע בכתב התביעה, או לכל הפחות בתשלום שנקבע על ידי המומחה, בצירוף ריבית והצמדה בהתאם להסכם הניהול, ובתוספת מע"מ כדין.

ג. טענות הנתבעת:

24. הנתבעת מפנה אף היא להוראות הסכם הניהול הקובע , כי עליה לשאת ב **"הוצאות סבירות"**. לטענת הנתבעת הדיון בתובענה אמור להיבחן אך ורק במסגרת הוראות חוק המקרקעין, ועל כן , גם בחינת השאלה מהן הוצאות סבירות אמורה להיבחן על פי

- ההסדרים שבחוק המקרקעין . לשיטת הנתבעת , כל אימת ששיטת החישוב או הוצאה מסוימת אינם עולים בקנה אחד עם חוק המקרקעין , הרי שמדובר בדרישה שאינה סבירה, והנתבעת פטורה מלשלם עליה.
25. עוד טוענת התובעת כי מכל מקום , בהתאם לחוק המחאת חיובים , התשכ"ט-1969 (להלן: **"חוק המחאת חיובים"**) , ריאלקו לא היתה רשאית להמחות והתובעת לא היתה רשאית לקבל המחאה של חובות חייבים . ממילא, כך לשיטת הנתבעת נשמטת הקרקע תחת דרישת התובעת.
26. לטענת הנתבעת , ההוצאות שנקבעו על ידי התובעת הינן הוצאות שנראו בעיניה כמתאימות להסכם הניהול , והתובעת אף הגדיל ה לעשות כאשר דרשה ריבית גבוהה במיוחד.
27. לטענת הנתבעת , מאחר שבמועד הרלוונטי לכתב התביעה לא היה הבניין רשום כבית משותף, חל התקנון המצוי שבחוק המקרקעין . לטענת הנתבעת שיטת חיוב וחישוב השטחים של התובעת, חרגה מהכללים שקבועים בחוק המקרקעין , ובתוך כך אף הוסיפה 38% עבור השטח המשותף שלא כדין.
28. הנתבעת הדגישה, כי סיכומיה הינם בשאלות המשפטיות שבין הצדדים ואין היא נדרשת לעניינים שבעובדה . הנתבעת פעלה כן , כך לדבריה , לאור האמור בהחלטתי מיום 30.11.10, כאשר לשיטתה החלטה זו מתירה לה לא להתייחס לטענות העובדתיות בשלב זה כלל.
29. לטענת הנתבעת חוק המקרקעין הוא שקובע היאך יש למדוד את שטחי המשותפים של הבניין. לטענתה, על פי חוק המקרקעין השטחים המשותפים הם כל שטח הבניין , ואין להחסיר מאלה מאומה . לטענתה, מדידה חייבת להיעשות על ידי מודד מוסמך . כמו כן, לטענתה, יש להתייחס, כך על פי חוק המקרקעין , לבניין כיחידה אחת ועל פיה לחשב את שטח היחס בין שטח "נטו" של יחידת דיור (כולל קירות) לבין שטח הבניין כולו . לטענת הנתבעת, כל חישוב אחר נוגד את חוק המקרקעין וממילא בטל.
30. לטענת הנתבעת **"הרכוש המשותף"**, הינו זה המוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין. בנוסף, סעיף 57(א) לחוק המקרקעין קובע מה הוא החלק של כל בעל דירה ברכוש המשותף . כן נקבע בסעיף 58 לחוק מנגנון חלוקת הנטל בנשיאת ההוצאות , קרי, לפי יחס שטח הרצפה של הדירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות , אלא אם כן נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לטענת הנתבעת , מאחר שבתקופה הרלוונטית לא היה תקנון אחר לבניין , הרי שחלוקת הוצאות התקנון המצוי, שאינו קובע הוצאות שונות מאלה הקבועות בחוק כאמור לעיל.
31. לשיטתה של הנתבעת , אין גם מקום לאבחנה שעשתה התובעת כמו גם המומחה בין הקומות השונות, וכי כל עוד לא הוכרז הבניין כבית מורכב , בהתאם לסעיף 59(ב) לחוק, יש להתייחס לכל חלקי הבית המשותף באופן שווה.

32. לאור הוראותיו הברורות של חוק המקרקעין, כך מוסיפה הנתבעת, אין לקבל את חוות דעתו של המומחה, שכן היא מבוססת על מפתח חישוב הוצאות השונה לחלוטין מזה הקבוע בחוק המקרקעין. בנסיבות אלו, אין לשיטת הנתבעת לתת משקל לחוות דעתו של המומחה.
33. הנתבעת טוענת כי ההוצאות היחידות שבגינן עליה לשאת הינן אלו הקבועות בסעיף 58 לחוק המקרקעין, ומעבר לכך לא מוטלת עליה חובה כלשהי.
34. הנתבעת אף טוענת, כי המדידה שהוגשה למומחה בוצעה מטעם חברה קשורה לתובעת, שהינה, כך לדברי הנתבעת, חברה אינטרסנטית. בהקשר לכך טוענת הנתבעת כי שטח דירתה כולל הרכוש המשותף, נקבע ל- 219.50 מ"ר, בעוד שבפועל שטחה הינו 160 מ"ר בלבד. לשיטת הנתבעת מדובר בתוספת של 37.2% לשטחה, ולא היה כל יסוד חוקי לכך.
35. הוסיפה הנתבעת וטענה כי על פי חוק המקרקעין אין אבחנה בין מקרה בו הדירה מאוכלסת לבין מקרה בו היא ריקה, ולפיכך לא היה כל מקום להכנסת פרמטרים אלו לבסיס החיוב בהוצאות האחזקה. הנתבעת טענה בעניין זה עוד כי חישוב זה הביא לכך שיחידות המצויות בבעלות חברה קשורה של התובעת נהנו מתשלום מופחת, וזאת למעשה על חשבון הנתבעת ודיירים אחרים.
36. הנתבעת אף הלינה על כך שעל פי חוק המקרקעין, יש לקבוע קודם האם ההוצאה הנתענת דרושה ורק לאחר מכן לבחון אם היא סבירה, דבר, שלשיטת הנתבעת לא נעשה במקרה דנן.
37. הנתבעת הפנתה לפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון בע"א 4856/07 **לחאם ז"ל נ' רבתי לחאם ואח'** (פורסם באתר נבו), ממנו בקשה ללמוד כי כאשר נקבעו הסדרים סטטוטוריים, לא ניתן לחרוג מהם.
38. בשל כל האמור, דרשה הנתבעת כי ייקבע "שיש לנהוג על פי הקבוע בחוק המקרקעין, בכל מה שקבוע בו, ולהטיל על המומחה להגיש חוו"ד שמבוססת על הכללים שבחוק המקרקעין. רק לאחר ששלב זה יסתיים, אפשר לעבור לשלב השני (אם ההוצאה דרושה לפי הגדרות חוק המקרקעין ואם היא סבירה)".

ד. דיון והכרעה:

39. בטרם אפנה לגופם של דברים יש לתחום תחילה את מסגרת הדיון שבפנינו. הציר הראשון עליו סובב הדיון, שהוא גם הטבעי והרגיל בדיון בפני המפקח על רישום המקרקעין, הינו הוראות חוק המקרקעין, ובכלל זה, כמובן, הוראות התוספת הראשונה לחוק. ציר נוסף עליו סובב הדיון, שהוא טבעי פחות, ועם זאת לא פעם עולה אף הוא בדיון בפני המפקח

על רישום המקרקעין, הינו פרשנות הסכם הניהול, שנכרת בין צדדים לתובענה בקשר להסדרי הניהול וחובת האחזקה בבית.

40. ודוק: אכן, בלא מעט מקרים, ככל שיימצא כי התביעה הינה תביעה חוזית גרדא, כי אז אין התובענה בסמכות המפקח על רישום המקרקעין. אולם, ככל שיימצא כי אותו הסכם ניהול החליף את התקנון המצוי והפך הלכה למעשה ל"תקנון המוסכם", הרי שהמפקח על רישום המקרקעין מהווה אכסניה מתאימה לפרשנותו. על כן, ככלל, אין מקום לטענה כי על המפקח על רישום המקרקעין להתעלם מהסכמים שונים ומהתחייבויות שונות שנטלו על עצמם בעלי דירות בבית המשותף, ולפסוק את הדין אך ורק בהסתמך על התקנון המצוי שבחוק המקרקעין. על המפקח לבחון את כלל ההסדרים בין הצדדים, ולהכריע על בסיס כל הנתונים לא לו הסכמות הגיעו בעלי הדירות בנוגע לניהול ואחזקה של הרכוש המשותף בבית.

41. והנה, אם אמרנו כי אין להתעלם מהסכמים שנכרתו ביחס לניהול הוצאות הבית המשותף על דרך הכלל, על אחת כמה וכמה בענייננו. כאמור לעיל, במקרה דנן, הוגשה התובענה לבית משפט השלום, והיא הועברה למפקח על רישום המקרקעין מכח סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט. להווי ידוע, כי משעה שהועבר סכסוך על פי סעיף 79 לחוק בתי המשפט, קונה הערכאה הנעברת סמכות לדון בתובענה **"כאילו הובא העניין מלכתחילה לערכאה המוסמכת"** [ר' גם: א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה חמישית מעודכנת, 37]. בהינתן זאת, הרי ש במקרה דנן, וודאי שעלי לדון גם ביחסים החוזיים שבין הצדדים לתובענה, אף ללא קשר לחוק המקרקעין, גם אם מלכתחילה אין הדבר בסמכות המפקח.

42. דיוננו בשאלות שבמחלוקת סובב, על כן, בשני מעגלים: האחד, המישור החוזי הנובע מהסכם הניהול, והשני, היחסים בין בעלי דירות בבית משותף, לאור הוראות חוק המקרקעין. **אקדים את המאוחר ואציין, כי כפי שיובהר בהמשך, דומה כי במקרה דנן מעגלים אלו חופפים המה, דבר המביא לייתור חלק נכבד מהשאלות שבמחלוקת.**

43. נושא נוסף אליו אבקש להתייחס בטרם אפנה לגופו של עניין, הינו מעמדה של התובעת וסמכותי לדון בעניינה. ככלל, על פי סעיפים 72-73 לחוק המקרקעין, תביעה בפני המפקח על רישום המקרקעין רשאית להגיש רק אחד מהמנויים בסעיפים הנ"ל, קרי, בעל דירה, הנציגות וה"מתחזק". במקרה דנן, נראה כי התובעת עומדת בהוראות הנ"ל, ומכל מקום עלי לדון בעניינה.

44. בראש ובראשונה, מאחר שכאמור התובענה הועברה לפתחי לפי סעיף 79 לחוק בתי המשפט, ועל כן, סמכותי העניינית חולשת על תביעת התובעת.

45. יתרה מכך, במקרה דנן נראה, כי יש מקום לראות בתובעת כ"מתחזק" בהתאם לסעיף 71(ב) לחוק. יוסבר: אין חולק כי חברת ריאלקו מונתה בהסכם הניהול על מנת לנהל ולתחזק את הבית המשותף. הסכם הניהול נחתם על ידי כל בעלי הדירות, ומכאן שהתקבלה למעשה הסכמת הרוב הנדרש להיותה של ריאלקו "מתחזק" על פי חוק המקרקעין. בנוסף, בסעיף 5.2 להסכם, עליו חתמו בעלי הדירות, נקבע כי ריאלקו רשאית

להעביר כל זכויותיה וחובותיה על פי ההסכם לחברת ניהול א' חרת אשר תבוא בנעליה, ולפיכך יש לראות גם את התובעת כמי שקיבלה את ההסכמות הנדרשות בסעיף 71(ב) לחוק, להחלפת המתחזק. [לעניין זה, ולעניין הכרה בכך שחתימה של בעלי הזכויות על הסכמים נפרדים כמוה כ"החלטה" לעניין סעיף 71 (ב) לחוק ר': עש"א 5336-06-09, **ניהול שנקר 4 בע"מ נ' אבי זלצמן**, (פורסם בנבו). כן ר': תא"מ 6420/07 **מירב מגדל מבוא ירושלים אחזקות בע"מ נ' סימה ציליק** (פורסם בנבו)]. בנסיבות אלו, יש לראות בתובעת כ"מתחזק" במובנו של חוק המקרקעין.

46. הנה כי כן, עלי לדון בתביעת התובעת, בין אם היא "מתחזק" ובין אם אינה כזו.
47. נושא נוסף אליו עלי להתייחס בטרם אכנס לפרטי הדברים, הינו עמדת הנתבעת שלפיה שלב זה הינו רק שלב ביניים בפסיקת הד' ין, בהתבססה על האמור בהחלטתי מיום 30.11.10.
48. בכל הכבוד, נראה כי הנתבעת לא דייקה בהחלטה. בהחלטה הנ"ל נקבע מפורשות כי: "הסיכומים יעסקו **בכל** הנושאים שבמחלוקת" (ההדגשה שלי). כן נקבע כי: "אם יתברר, כי ישנן מחלוקות עובדתיות נוספות הדרושות להכרעה, יוזמנו הצדדים לדיון הוכחות נוסף. ככל שלא יהיה צורך בכך, יינתן פסק דין על פי החומר הקיים בתיק". תמוהה בעיניי התנהלות הנתבעת אשר בחרה ליטול דרור לעצמה ולהתמקד רק בטענות המשפטיות. הנתבעת לא היתה רשאית לעשות כן, ובפסק דין זה אתייחס לכל השאלות הרלוונטיות.
49. עתה אגש לגופו של עניין.
50. הבניין מושא התובענה, לא היה רשום במועד הרלוונטי כבית משותף, ואולם אין חולק כי ראוי היה להירשם ככזה (והוא אכן נרשם בסופו של יום כבית משותף). לפיכך, חל על ענייננו סעיף 77 לחוק המקרקעין הקובע כי: "**סעיפים 56, 57, 58, 59...71...ו-72 עד 77 יחולו על בית לפי פרק זה, בשינויים המחוייבים**". בנוסף, חל על ענייננו סעיף 77 לחוק המקרקעין הקובע כי: "**בית יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת**".
51. סעיף 58 לחוק המקרקעין קובע כי: "**בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנהג** לפי שטח יחס רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, **זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר**". בנוסף, נקבע בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי כי: "**החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה, אלא אם הסכים לה**". (ההדגשות לא במקור).
52. הוראות סעיף 58 לחוק וסעיף 12 לתקנון המצוי משלימות אחת את רעותה, ומהן ניתן ללמוד כי כל עוד לא נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר מזה שנקבע בסעיף 58 לחוק, אין

לחייב בעל דירה בחובה המטילה עליו חובות שלא היה חייב בהן מלכתחילה, אלא אם כן הסכים לכך בעל הדירה. אמנם, כל עוד לא הסכים בעל הדירה לשינוי, אין לשינוי תוקף מחייב כלפיו, אולם, במקביל, לאור הוראות סעיף 12 סיפא לתקנון המצוי, ככל שבעל הדירה הסכים לשינוי, הסכמתו גוברת על ההסדר שבסעיף 58 ומחייבת אותו. יפים לעניין זה דברי המלומד אייזנשטיין [א]. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, 166], אשר קבע, בהתייחס לסעיף 12 לתקנון כדלהלן:

“סעיף זה דומה לאמור בס יפא של 62(א) לחוק, כי בתקנון אין לקבוע או לשנות זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם... הרוב אינו רשאי לקפח את זכותו של המיעוט... או להטיל עליו תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק אלא בהסכמתו”. (ההדגשה לא במקור).

53. הסכמה זו של בעל דירה לשינוי החובות המוטלות עליו אינה א מורה להינתן דווקא במסגרת התקנון. כך ככלל, וקל וחומר כאשר הבית אינו רשום כבית משותף, והתקנון המצוי הינו “הסכם קונסטרוקטיבי” שבין הצדדים מכח סעיף 77ג לחוק. במקרה זה, וודאי שחתימה של בעל דירה על הסכם אחר, מחייבת אותו, ועונה על דרישות סעיף 12 לתוספת הראשונה לחוק המקרקעין. גם לעניין זה יפים דברי המלומד אייזנשטיין [א]. אייזנשטיין, שם, 290]: **“התקנון המצוי אינו אלא פיקציה הסכמית שקבע חוק המקרקעין בדבר היחסים ההדדיים בין בעלי הדירות בבית המשותף...”**. מכאן, שהסכמה זו ניתנת לשינוי בהסכם ספציפי שנחתם על ידי בעלי הדירות, וככל שנחתם הסכם כזה הוראותיו תגברנה.

54. במקרה דנן, אין חולק כי הנתבעת, כמו גם בעלי דירות נוספים בבניין, חתמו על הסכם הניהול [ר' גם: עמוד 8 שורה 20 לפרוטוקול]. פועל יוצא מכך שיש לראות בנתבעת כמסכימה לכך שהוראות ההסכם תגברנה, והוא מחייבה בהתאם לסעיף 12 סיפא לתקנון המצוי. חובתה של הנתבעת לעמוד בתנאי הסכם הניהול, הינה על כן חובה השואבת כוחה גם מהוראות חוק המקרקעין.

55. נוסף על כך, כאמור לעיל, מאחר שהועברה התובענה לידי מכח סעיף 79 לחוק בתי המשפט, חובה עלי לבחון את הסוגיה גם במשקפי דיני החוזים אף ללא קשר לחוק המקרקעין. ברי, כי הנתבעת חייבת לעמוד בהסכם עליו חתמה, שכן חוזים יש לקיים, ומכאן שלתוצאה זה שלפיה הנתבעת מחויבת להסכם הניהול, נגיע גם לאור דיני החוזים. נראה כי בעניין זה, אין צורך להרחיב את הדיבור.

56. הנה כי כן, בין מכח דיני החוזים, ובין מכח דיני המקרקעין, על היחסים בין התובעת לנתבעת חולש הסכם הניהול. מכח דיני החוזים מחייב ההסכם, ככל הסכם ששני צדדים חתמו עליו. מכח דיני המקרקעין, שכן, כאמור, הסכם הניהול שנחתם על ידי כל בעלי הדירות, מהווה הסכמה לשינוי הוראות התקנון המצוי ו החלתו על יחסי הצדדים. לא זו אף זו, כפי שהובא לעיל, ניתן לראות בחתימת בעלי הדירות על הסכם הניהול כהסכמה

למינויה של חברת הניהול "כמתחזק", על כל המשתמע מכך [ר': פסקי הדין המוזכרים לעיל].

57. מאחר שמצינו כי הסכם הניהול, הוא המסדיר את מערכת הזכויות והחובות של הצדדים (וזאת כל אימת שלא נקבע אחרת) בין בהסכם מאוחר ובין בתקנון מאוחר שנרשם לבית המשותף), הרי שכדי להכריע בשאלות מושא המחלוקת, ובכלל זה היקף ההתחייבות של בעלי הדירות בהסכם, עלינו להידרש לפרשנותו של הסכם הניהול.

58. להווי ידוע, כי על פי סעיף 25(א) לחוק החוזים (אשר תוקן במסגרת תיקון מס' 2 לחוק): **"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו"**. בית המשפט העליון דן בפרשנותו של הסעיף הנ"ל לאחר תיקונו, והבהיר כי אין בו כדי לשנות את ההלכה שנקבעה ב דנ"א 2045/05, **ארגון מגדלי ירקות – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל** (פורסם בנבו), ושלפיה התחקות אחר אומד דעת הצדדים אינה רק מתוך לשונו של ההסכם אלא דורשת בחינת נסיבותיו והתכליות שביקש להגשים. יחד עם זאת, הבהיר בית המשפט העליון, כי לאור הוראות הסעיף לאחר תיקונו, מקום בו לשונו של ההסכם ברורה וחד משמעית, היא זו התוחמת את אומד דעתם של הצדדים [ר': רע"א 1452/10, **מפעל הפיס בע"מ נ' אלחנן טלמור** (פורסם בנבו); השווה גם לע"א 5856/06 **אמנון לוי נ' נורקייט בע"מ** (פורסם בנבו)].

59. נבחן אפוא את הוראות הסכם הניהול הרלוונטיות על רקע האמור.

60. סעיף 9 להסכם הניהול חד משמעי והוא קובע כדלהלן:

9.1. **הדייר מתחייב לשאת ביחס עם יתר הדיירים בכל ההוצאות הסבירות הכרוכות בניהול וביצוע השירותים על ידי החברה.**

9.2. **ההוצאות שהחברה תוציא תהיינה ההוצאות הבאות:**

9.2.1. **הוצאות הנוגעות לניהול וביצוע השירותים באופן כללי בבניין והניתנים ו /או המשרתים את כלל הדיירים בבניין. בהוצאות אלה ישתתפו כלל הדיירים על בסיס קריטריונים שיקבעו על ידי החברה ויאושרו על ידי רואה החשבון שלה.**

9.2.2. **הוצאות בקשר לניהול וביצוע השירותים הניתנים ו /או המשרתים רק חלק מהדיירים ולא את כולם. בהוצאות אלו ישתתפו אותם דיירים שלטובתם ו /או בגינם הוצאו אותם הוצאות ו זאת על בסיס קריטריונים שיקבעו על ידי החברה ויאושרו על ידי רואה החשבון שלה. (ההדגשות לא במקור).**

...

9.5. **בתמורה לטיפול החברה בניהול וביצוע השירותים בהתאם להסכם זה, ישלם הדייר לחברה דמי ניהול בשיעור של 15% מכל ההוצאות הסבירות הקשורות בניהול וביצוע השירותים ("להלן: "דמי ניהול"). דמי הניהול יהיו חלק בלתי נפרד מן ההוצאות ויהיו את שכרה של החברה תמורת ההתחייבות בהסכם.**

61. ניתוח לשון הה סכם מביא למסקנה חד משמעית , שלפיה ההסכם בא לשנות מהקריטריונים לחיוב שנקבעו בחוק המקרקעין , תוך שנקבע במפורש כי אלה ייקבעו על ידי החברה ויאושרו על ידי רואה החשבון שלה . משמעותו של סעיף זה שהנתבעת קיבלה על עצמה הסדרים **מיוחדים** שיקבעו לניהול הבניין , השונים מהוראות התקנון המצוי . חתימתה על הסכם זה מחייבת אותה , והיא מהווה הסכמתה לשינוי מפתח חישוב ההוצאות כאמור בסעיף 58 סיפא לחוק וסעיף 12 סיפא לתוספת הראשונה לחוק.
62. ניתן היה לעצור הדיון בעניין הסכמתה של הנתבעת לשינוי הקריטריונים לחישוב ההוצאות בנקודה זו, שכן לשונו של ההסכם ברורה וחד משמעית . למעלה מהדרוש אציין, כי נראה כי גם בחינת תכליתו של ההסכם ונסיבותיו, מעידים על כך שהצדדים להסכם התכוונו לקבוע הסדרים שונים מאלו שנקבעו כברירת המחדל בחוק המקרקעין, וזאת, לאור העובדה כי מדובר בבניין משרדים שאינו בית דירות רגיל , ותכליתו שונה מזו של בית מגורים רגיל . כבר בפרק ה "הואילים" להסכם, מובהר כי מדובר בבניין ש "מיועד לשמש למשרדים, ליעוד מסחרי ולחניון ." כן נקבע בסעיף 3 כי חברת הניהול (במועד הרלוונטי – ריאלקו), תהיה זכאית לקבוע לפי שיקול דעתה את היקף השירותים הניתנים סוגם וטיבם . כן נקבע בסעיף זה כי חברת הניהול תהא זכאית להחליט על מועד ביצוע השירות ואופן ההספקה . בהסכם אף נקבע "סעיף השתחררות" – סעיף 14.2 להסכם, שקבע כי רק ברוב מי אחד מאוד (בעלי דירות המחזיקים ב- 90% משטח הבניין) ניתן יהיה להודיע על הפסקת ההתקשרות עם חברת הניהול, וזאת, בניגוד להוראה המקבילה בחוק המקרקעין [רוב רגיל במקרה של נציגות רגילה , או רוב של שני שלישים במקרה של מתחזק]. דברים אלו מעידים על כך שההסכם נועד, בין היתר, לקבוע מנגנוני ניהול שונים מאלה שנקבעו ב"תקנון המצוי", וזאת לאור ייחודיותו של הבניין ומטרתו.
63. הנה כי כן, פרשנות הסכם הניהול מביאה למסקנה, כי הוא נועד לשנות מהקריטריונים שנקבעו בחוק המקרקעין ולקבוע מנגנוני חיוב שונים לאחזקה וניהול הבית המשותף . בתוך כך, קובע הסכם הניהול כי מנגנוני החיוב אמורים להיקבע על ידי חברת הניהול הרלוונטית, ועל ידה בלבד.
64. משנמצא כי הסכם הניהול הוא המחייב את הצדדים ביחס להשתתפות בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף בבניין, ומשנמצא כי הוא אכן נועד לשנות את ההוראות הקבועות בחוק המקרקעין ולקבוע קריטריונים שונים, הרי שעלינו לבחון מה קובע ההסכם ביחס להיקף החיוב של כל בעל דירה.
65. הסעיפים הקובעים את התשלום שעל בעל דירה לשלם הינם סעיף 9.1 וסעיף 9.5 להסכם הניהול. סעיפים אלו קובעים כי ההוצאות בהן יחוב בעל דירה , ועל בסיסן ישולם גם שכרה של התובעת, הינן "**ההוצאות הסבירות**" הקשורות בניהול וביצוע השירותים. רוצה לומר, הסכם הניהול קבע, כי הבסיס למפתח החיוב הינו **סבירות** החיוב וההוצאה.
66. על כן, כדי להכריע בשאלה האם כדין פעלה התובעת יש לבחון את סבירות פעולותיה, הן ביחס לקריטריונים שקבעה לחיוב בעלי הדירות והן ביחס לכל הוצאה שקבעה . מובן, כי

אף שאלת ה"סבירות" אמורה להיבחן על רקע הסכם הניהול ונסיבותיו. בתוך כך, יהא עלינו לבחון את השאלה האם מנגנון החיוב שנקבע על ידי התובעת הינו סביר ומקובל בנסיבות העניין, וכמובן את השאלה האם ההוצאות שנדרשו בפועל, משקפות את המצב הנהוג בבניינים דומים, שנועדו למטרות דומות.

67. לצורך כך מונה, עוד על ידי בית המשפט השלום, המומחה מר אורמן דן. בחוות דעת התייחס המומחה לטענות הצדדים בעניין שיטת החיוב באופן כללי, ובחן את סבירותה של כל הוצאה נטענת. בדיון שהתקיים בפני התייחס המומחה לשאלה האם הקריטריונים שנקבעו על ידי התובעת לחיוב בעלי הדירות, הינם קריטריונים המקובלים בבנייני משרדים, ואישר כי על פי בדיקתו בבנייני משרדים, באופן עקרוני (בשינויים כאלה ואחרים) הקריטריונים שנקבעו על ידי התובעת הינן הקריטריונים הנהוגים. כך העיד המומחה בעניין זה:

ש: ...האם בחישוב הרכוש המשותף בחוו"ד פעלת על פי ההגדרות בסעיף 57 לחוק המקרקעין?

ת: לא התבקשתי מבית משפט לתת חוו"ד על בסיס חוק המקרקעין אלא התבקשתי לבדוק האם ההוצאות הן סבירות בנסיבות העניין וכן לבדוק את חישוב השטחים בהתאם למומחיותי. אני בדקתי את כל הבניין בשלמות בדקתי מה הכי הוגן... (ההדגשה לא במקור).

...

ש: האם נכון שכאשר הצגתי בפניך שאם כב' המפקח יקבע שאתה צריך לעשות את החישוב על פי חוק המקרקעין אתה תפעל בהתאם?

ת: התייחסתי למה שביקש בית משפט. אם היית מבקש ממני הייתי עושה זאת, אבל זה היה מעוות את התוצאה. אם הייתי נותן חוו"ד על פי עו"ד כהן זה היה פותח הרבה תביעות ומעוות את העניין.
(ההדגשות לא במקור)

...

ש: האם בדקת את התקנון המצוי?

ת: הלכתי לעוד בניין משרדים ובדקתי איך מתנהל שם והתברר לי שזה אותו הדבר. לא בדקתי את התקנון המצוי.

ובהמשך, כאשר נשאל המומחה בנוגע ליחס "ברוטו" "נטו" העיד המומחה כי:

ש: אתה מכיר בניינים עם יחס של נטו ברוטו 37.2%

ת: אני מכיר אפילו הרבה יותר.

ש: מה מקובל בין הנטו לברוטו האם נכון שבד"כ מדובר בפער של עד 25%.

ת: יש 30% ויש 35% הכל תלוי בשימושים ובאופי הבניין.

68. מדבריו של המומחה , שהיו אמינים ביותר כשלעצמם , ולא נסתרו על ידי מומחה אחר , עולה כי שיטת החיוב בו נקטה התובעת , בשינויים מסוימים עליהם עמד המומחה , הינה שיטה מקובלת בבניינים כדוגמת הבניין , וממילא יש לראות בה שיטה "סבירה" העומדת בקנה אחד עם הוראות הסכם הניהול . משמעות הדברים היא כי התובעת רשאית היתה, מכח הסכם הניהול (אשר, כאמור, מחייב הן מבחינת דיני החוזים והן לאור חוק המקרקעין), לקבוע את הקריטריונים (בשינויים הנדרשים על פי חוות דעת המומחה) לחלוקת ההוצאות, כפי שקבעה.

69. מכאן עבר המומחה לבחינת ההוצאות גופן , ובדק כל הוצאה האם היא סבירה . המומחה בחן הוצאה הוצאה , וקיבל את עמדת התובעת ברובה תוך שלגבי מספר הוצאות קבע כי הן בלתי סבירות. גם בנושא זה היתה עדותו של המומחה אמינה ביותר ולא מצאתי בה כל דופי. בעניין זה יש לציין כי במהלך עדותו תיקן המומחה את חוות הדעת בהקשר לסעיף 9.15 המתייחס לאגרות , וקבע כי ככל שמדובר באגרות בית משפט הרי שיש לראות בהוצאה זו הוצאה סבירה. הוצאה זו יוחסה לשנת 2004, ולפיכך אין היא מעניינתנו.

70. המומחה אף התייחס למדידה שבוצעה לצורך בסיס החיוב והבהיר בעדותו כי :

ש: באיזה תשריטים השתמשת?

ת: בתשריטים של מודד מוסמך. אני מאשר שאת התשריטים העבירו לי

ר.ס. סיטי. אני גם מדדתי את כל 3 המשרדים בשטח את הדברים.

משעה שהסתמך המומחה על תשריט מודד מוסמך ואף מדד בעצמו בשטח את הדברים , לא מצאתי פסול בכך שהמומחה הסתמך על תשריטי המדידה שהו עברו לו . לא למותר לציין כי הנתבעת לא הגישה חוות דעת הסותרת מדידות אלו.

71. בסופו של דבר סיכם המומחה כי שיטת החיוב הנהוגה על ידי התובעת הינה מקובלת וסבירה בנסיבות העניין , ולאחר תיקונים בגין פרמטרים שונים בתחשיב התובעת , קבע המומחה מהן ההוצאות הסבירות , וכנגזרת קבע כי דמי הניהול הסבירים שעל הנתבעת היה לשלם בגין התקופה בכתב התביעה הינם בסך של 50,001 ₪ (קרן).

72. כאמור, עמדת המומחה היתה אמינה ביותר בעיני , ולפיכך, אני מקבלת, וקובע כי הסכום שקבע המומחה אכן משקף את דמי הניהול שעל התובעת לשלם (קרן).

73. על פי ההסכם יש להוסיף על סכום הקרן מע"מ כדין (סעיף 9.4 להסכם הניהול), וכן תוספת הצמדה וריבית חודשית בשיעור של 3% (סעיף 12 להסכם הניהול). לא מצאתי כל טעם להורות כי סעיף זה לא יחייב את הנתבעת , ולכן אין מנוס מקביעה כי על הסכום שקבע המומחה (50,001 ₪) יתווסף מע"מ כדין וכן הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של 3% כאמור [השווה לפסק הדין בעניין מירב מגדל המובא לעיל].

ה. בשולי הדברים:

74. כאמור, הגעתי לתוצאה שלפיה יש לקבל את עמדתה העקרונית של ה' תובעת. לתוצאה זו הגעתי מניתוח דיני החוזים ודיני המקרקעין גם יחד. מעבר לכך, חשוב להעיר כי יש ממש גם בטענת התובעת, כי באופן עקרוני עת נדונה תובענה לתשלום דמי השתתפות באחזקת הרכוש המשותף בפני המפקח, אין מקום לטענות נתבע, החולק על גובה הסכום או טוען לאי תפקוד ראוי של הנציגות. אכן, הלכה היא כי הא בהא לא תליא, וכי ככל שיש לנתבע טענות על אופן הניהול ו גובה הסכום, עליו לפנות לאסיפה הכללית ולאחר מכן למפקח [ר': רע"א 294/87 שלום נ. נציגות הבית המשותף (פורסם באתר נבו); ע"א (מחוזי-ת"א) 204/79, וייזר נ' נציגות הבית המשותף מרחוב חן, פס"מ, תשמ"ד (א), 503]. יחד עם זאת, במקרה דנן כמוסבר לעיל, ממילא היה עלי להידרש לכל הסוגיות לאור אופייה של התובענה שהובאה לפתחי, ולפיכך דנתי גם בהיקף החיוב.

ו. סוף דבר:

75. אשר על כן הנתבעת תשלם לתובעת סך של 50,001 ₪ בצירוף מע"מ כדין ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כאמור. כן תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 7,500 ₪.

ש. הייזלר
מפקח בכיר על רישום המקרקעין